

## Corte d'Appello Milano - Sez. III - Sentenza del 5/12/2022 n. 3638

nelle persone dei seguenti magistrati:  
dr. Irene Formaggia -Presidente  
dr. Maria Paola Varani -Consigliere rel  
dr. Alessandro Bondi' -Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1230/2022 promossa in grado d'appello da xxx SPA (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in presso lo studio dell' avv. xxx, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO COMUNE DI (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATO avente ad oggetto: locazione di immobile ad uso diverso

#### Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato il 21 aprile 2022 e ritualmente notificato la società S.p.A. ha chiesto la totale riforma della sentenza n. 566/22 pubblicata il 9/3/2022, con la quale il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione dalla predetta società proposta avverso il decreto n. 2873/2020, emesso in data 28/10/2020, su istanza del Comune di , di ingiunzione del pagamento di canoni dovuti per la locazione di porzione di terreno immobiliare.

Si è costituito in giudizio il Comune per eccepire l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza. All'udienza di discussione del 16 Novembre 2022 la Corte, sentiti i difensori delle parti, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'articolo 437 codice di procedura civile, dando lettura del dispositivo allegato al verbale d'udienza.

Lamenta l'appellante l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e sostiene che l'art. 133/1 lett. b del D.Lgs. n. 104 del 2010 deve essere inteso nel senso che la competenza dell'AGO non potrebbe estendersi alle controversie che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo.

**Il motivo è infondato.** L'art. 133, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, delle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai Tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La pretesa monitoria azionata dal Comune di Renate concerne il pagamento del corrispettivo di

locazione di porzione di area per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, per l'esecuzione di un rapporto di natura privatistica, il contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo stipulato il 30.12.2014 con . ( divenuta spa, poi l, fusa per incorporazione nella società . spa), che esula da una concessione amministrativa.

La giurisdizione e appartiene al giudice ordinario, in forza di un rapporto contrattuale che, non avendo un provvedimento concessorio sottostante, si esplica esclusivamente nell'ambito dell'autonomia privata senza alcun esercizio di poteri autoritativi della P.A..

Lamenta l'appellante la qualificazione dell'area concessa in uso locatizio quale parte del patrimonio disponibile del Comune effettuata dal primo Giudice, oggetto di libera contrattazione tra le parti. La società appellante, sul dedotto presupposto dell'applicabilità della disciplina del D.Lgs. n.259 del 2003 esclusivamente alle aree indisponibili, prospettando l'appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune per il fatto che l'area oggetto del contratto è collocata all'interno del mappale 24 del foglio (...), classificato nella categoria impianti sportivi, occupato dagli impianti sportivi di via M., afferma che la scelta del Comune di destinare le aree all'uso di infrastrutture per l'esercizio di telecomunicazioni rende le aree stesse soggette a tutte le norme relative alle aree indisponibili e sottopone l'ente ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003.

**Il motivo, compiutamente illustrato nelle pagine 6-10 dell'atto di appello, è infondato.**

Richiama la Corte l'art. 826 cod. civ. che stabilisce che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province o dei comuni, i beni destinati a sedi di uffici pubblici e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, in particolare va richiamato il consolidato orientamento (Cass.Sez. Unite n. 21991 del 2020 e Cass. S.U. 15.7.1999, n. 391 ), secondo cui affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; dirimente è l'inserimento del bene nei beni pubblici in senso stretto, inserimento per il quale occorre un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui poi il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti.

Ne consegue che, in assenza di un atto amministrativo del Comune evidenziante la specifica volontà dell'ente di destinare l'area in oggetto all'esercizio di un servizio di interesse pubblico proprio dell'ente comunale, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione dell'area oggetto del contratto inter partes alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico, quale l'esercizio di una attività sportiva.

La destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente e l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente (Cass. 9.6.1987, n. 5024; Cass. 1.12.1985, n. 652).

**Non rientrando nelle attribuzioni del Comune l'esercizio del servizio di telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale, e deve ritenersi che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.**

L'appellante, con i rilievi esposti nelle pagine da 11-16 dell'atto di appello, censura la sentenza per omessa motivazione in relazione all'applicabilità al rapporto inter partes dell'art. 8 bis del D.L. n. 153 del 2018, per avere il Tribunale omesso la motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 93 CCE nella sua portata successiva al D.L. n. 135 del 2018, convertito nella L. n. 12 del 2019, che con la disposizione normativa dell'art.8 bis di natura innovativa e non interpretativa, imporrebbe agli enti pubblici il divieto di imposizione di canoni diversi dalla Tosap anche nei rapporti di natura privatistica ed indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene oggetto di godimento.

Il motivo è infondato. L'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 cd. Codice delle comunicazioni elettroniche che vieta l'imposizione di onere finanziario, reale o contributo "in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica", fatta salva l'applicazione della TOSAP o della COSAP, trova applicazione nell'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione da parte dei gestori telefonici appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile, infatti in questo caso non possono essere imposti ulteriori oneri, come previsto dal primo comma, al di fuori di TOSAP /COSAP come stabilito nel secondo comma. L'art. 93, facendo salva l'applicazione della TOSAP e del COSAP, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati appunto alla capacità "impositiva" degli Enti, non certo in relazione ai beni del patrimonio disponibile, verso i quali gli Enti si atteggiavano a meri proprietari che ne dispongono in via contrattuale, senza esercitare poteri amministrativi o impositivi, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.

L'art. 8-bis, comma 1, lettera c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 recita: "L'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto". Il D.Lgs. n. 207 del 2021 ha riformato il D.Lgs. n. 259 del 2003, sostituendo l' art. 93 con un nuovo art. 54, che stabilisce " fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12".

Considerato il richiamo all'art. 1 comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito il c.d. canone unico, che prevede quale presupposto "l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico" ex art. 1 comma 819 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, non può dubitarsi che non sia stata operata alcuna estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003, rimasto limitato ai beni demaniali o al patrimonio indisponibile.

Secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe poi considerato la ricaduta interpretativa dell'art. 1, comma 831-bis della L. n. 160 del 2019, come modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che avrebbe chiarito definitivamente lo spirito dell'art. 93, non distinguendo tra impianti presenti su aree disponibili od indisponibili, facendo riferimento ad un canone massimo per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, a fronte del quale è dovuto un solo importo predeterminato nella somma di Euro 800,00, esclusa ogni altra forma di corrispettivo. Con riguardo al motivo rileva il Collegio, a parte l'inapplicabilità temporale della norma per la valutazione della legittimità dell'ingiunzione di pagamento del 28.10.2020 in relazione alla debenza di canoni decorrenti dal secondo trimestre 2018, che nessun elemento insito nella citata disposizione autorizza a ritenere che la norma non abbia il medesimo presupposto impositivo del canone unico previsto dal comma 816 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Infine parte appellante lamenta la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado, in via subordinata, dell'art. 88 D.Lgs. n. 259 del 2003 che impone agli esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni di consentire, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

**Il motivo non può essere accolto** considerato che l'appellante non ha in alcun modo chiarito quali sarebbero le circostanze concrete del rapporto locatizio tali da far ritenere la sussistenza di condizioni non eque e discriminatorie nel suo aspetto economico e tali da legittimare lo svolgimento di un sindacato in relazione al quantum del canone pattuito dalle parti.

L'appello va perciò rigettato, con conseguente regolamentazione delle spese del grado che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri fissati dal D.M. n. 147 del 2022.

Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 15 del 2002, comma inserito dall'art. 1 c. 17, L. n. 228 del 2018.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SPA con l'avv. -appellante-CONTRO COMUNE DI con l'avv. i -appellato Avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 566/2022, pubblicata in data 09/03/2022, così provvede:

1. rigetta l'appello;

2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.946,00 di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 16/11/2022.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2022.